

1500989-34.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... vê, o réu confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, porém, tentou isentar o acusado Wesley, dizendo que não o conhecia.

Quanto ao tráfico em si, a confissão livre e espontânea prestada no processo serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500989-34.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500989-34.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2182994/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 18909824 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2022/21/309 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2182994 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2182994 - 01º D.P. BIRIGUI, 2022/21/309 - 01º D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATA CRISTOFER DA SILVA FERRAZ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500989-34.2021.8.26.0603 (Controle nº 1398/21).

VISTOS.

JHONATA CRISTOFER DA SILVA FERRAZ e WESLEY CARLOS FIGUEIREDO SOARES, qualificados nos autos, foram presos em flagrante delito, denunciados e viram-se processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de julho

de 2021, por volta das 18h40min, no imóvel localizado à Rua Elias Antônio, nº 625, Vila Pontes, nesta cidade e comarca de Birigui, em concurso de agentes, traziam consigo 07 (sete) tijolos de maconha, pesando um total de 6.891,7 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisória de fl. 34 e laudo toxicológico de fls. 155/157.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados (fl. 172) e apresentaram defesa escrita às fls. 179/180, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 09 de dezembro de 2021 (fls. 193/194).

Na instrução, foi colhido o depoimento de 01 (uma) testemunha arrolada em comum, sobrevivendo, ao final, os interrogatórios dos réus (fls. 244/245).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da ação, absolvendo-se o réu Wesley e condenado o acusado Jhonata, nos exatos termos da denúncia (fls. 255/260).

A defesa do réu Jhonata, pediu o reconhecimento da confissão espontânea, compensando-se com a agravante da reincidência, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Por fim, pleiteou o direito de apelar em liberdade (fls. 265/269).

Por sua vez, a defesa do réu Wesley, concordando com a acusação, pediu a sua absolvição e a consequente revogação da prisão preventiva (fl. 272).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06).

A ação penal é totalmente procedente, respeitado o entendimento exposto pela acusação quanto ao réu Wesley.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria deste crime narrado na denúncia (para ambos os acusados) ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); as notas de culpa (fls. 10/11); o boletim de ocorrência (fls. 41/43); o auto de apreensão (fl. 22); o laudo de constatação prévia (fl. 34); o relatório policial (fls. 132/133); os laudos periciais (fls. 152/154 e 155/157); o depoimento da testemunha e a confissão apresentada pelo acusado Jhonata e a contraditória e indigesta negativa trazida pelo réu Wesley, em ambas as fases da persecução penal.

O réu Jhonata, na delegacia, disse que é usuário de drogas e foi ao local para comprar entorpecentes, quando foi abordado, sozinho, no portão da casa e não estava com drogas. Afirmou que não conhece Wesley e não sabe informar quem é Francis (fl. 07).

Em juízo, confirmou que a droga era sua, destinada para comercialização. Disse que alugou verbalmente a casa, de uma pessoa chamada Carol, portanto as chaves encontradas eram suas. Afirmou que não conhece Francis, nem viu o corréu Wesley. Narrou que, na data dos fatos, os policiais encontraram a droga embaixo da cama, e que não tentou fugir, nem dispensar os entorpecentes. A balança estava na cozinha e era utilizada para pesar a droga. O dinheiro apreendido (R\$ 20,00) era oriundo da venda de entorpecentes (fls. 244/245).

Como se vê, o réu confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, porém, tentou isentar o acusado Wesley, dizendo que não o conhecia.

Quanto ao tráfico em si, a confissão livre e espontânea prestada no processo serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

Contudo, a versão do acusado, ao tentar afastar a responsabilidade da corréu está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado.

Verifica-se que o acusado Jhonatan apresentou contradição em seus interrogatórios, uma vez que na delegacia, disse que foi até o local comprar drogas e foi abordado no portão da casa. Em juízo, por sua vez, alterou totalmente a versão e afirmou que estava dentro de casa e os policiais encontraram a droga debaixo da cama.

Por sua vez, o corréu Wesley, na delegacia, disse que é usuário de drogas e naquele dia, estava indo até a casa de Jhonata, com o carro da sua irmã, para comprar drogas, quando foi abordado pelos policiais, antes mesmo de chegar na residência. Afirmou que não conhecia Jhonata, nem Francis e que estava sem dinheiro, pois iria ao banco sacar a quantia para comprar os entorpecentes (fls. 08/09).

Em juízo, negou a prática criminosa. Disse que foi deixar a chave de uma chácara na casa do seu avô e retornava para casa da sua mãe, quando passou pela praça, viu rapazes fumando e perguntou quem vendia drogas. Esses rapazes indicaram o local. Deixou o carro na esquina e foi até a casa de Jhonata, e comprou uma porção de maconha, por 20 reais. Quando voltava para o carro foi abordado pelos policiais e levado até o portão da casa de Jhonata e um dos policiais entrou na residência. Em seguida os policiais voltaram e questionavam Jhonata sobre as drogas, momento em que um dos policiais surgiu com o saco com entorpecentes, falando que eram deles. Não disse aos policiais que iria ajudar transportar droga e negou conhecer Jhonata. Esclareceu que na delegacia disse que foi abordado antes de comprar a droga, por medo de retaliação (fls. 244/245).

Como se vê, o acusado Wesley também apresentou contradições. Na delegacia, disse que estava indo comprar drogas, quando foi abordado pelos policiais. Em juízo, afirmou que já tinha comprado entorpecentes de Jhonatan quando foi abordado. Na fase policial afirmou, também, que estava sem dinheiro e iria sacar no banco para comprar os entorpecentes. Em juízo, por sua vez, disse que comprou o entorpecente por R\$ 20,00.

Há também contradições entre os interrogatórios dos acusados. O corréu Jhonatan disse que foi abordado dentro da sua residência e que mostrou onde estavam os entorpecentes. O acusado Wesley, por outro lado, afirmou que Jhonatan foi levado até a frente da residência pelos policiais e, neste momento, um dos policiais apareceu com o saco de entorpecentes.

Diante de tantas contradições apresentadas por ambos os acusados, relacionadas a pontos de fundamental relevância para o deslinde da causa, não há como se dar credibilidade às versões apresentadas pelos acusados, que restaram contraditórias e isoladas, se cotejadas às demais provas coligidas sob o crivo do contraditório, mormente às unânimes e coesas versões dos policiais.

Não bastassem os elementos de prova até aqui analisados, as demais provas produzidas na instrução dão conta da prática de tráfico de drogas pelos dois acusados.

Com efeito, a testemunha Fabiano de Jesus Barros Gomes, policial militar, ouvido em ambas as fases, relatou que estava em patrulhamento, quando recebeu a informação de que na residência de fundos, localizada na Rua Elias Antonio, nº 625, teria drogas armazenadas. Ao chegarem no local, viram o acusado Wesley em pé, na calçada, sozinho, próximo ao portão, vigiando o quintal da casa. Na sequência, Jhonata saiu, com um saco plástico. Quando viram a viatura policial se aproximar, o réu Wesley fugiu, mas foi detido. O acusado Jhonata jogou o saco no imóvel vizinho e foi detido. Dentro do saco plástico havia 07 tijolos de maconha e uma balança digital. Com Jhonatan encontraram R\$ 20,00 e duas chaves da residência. Wesley disse que estava na casa com Jhonata e iria ajudá-lo transportar o entorpecente. Jhonata afirmou que a droga era de uma pessoa chamada Francis que seria o dono da casa e que iria transporta-la. Jhonata disse que conhecia Wesley (fls. 03/04 e 244/245).

No mesmo sentido o depoimento do policial Gustavo Domingos Faria Fronho, ouvido apenas na delegacia (fls. 05/06).

Os policiais confirmaram que localizaram quantidade considerável de entorpecentes e que o réu Jhonatan assumiu que iria transportar o entorpecente e Wesley confirmou que ajudaria no transporte.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tais depoimentos somente não terão valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos. No que se refere ao entorpecente, a perícia apontou que consiste realmente em "maconha" (exame químico-toxicológico de fls. 155/157).

De outra parte, a grande quantidade de entorpecente apreendido, ou seja, 6.891,7 gramas de maconha, as circunstâncias da abordagem dos réus (denúncia de tráfico de drogas); a forma de acondicionamento da droga (tijolos), a apreensão da balança de precisão e dinheiro, a confissão parcial do réu Jhonata; estão a caracterizar a traficância.

Não se pode olvidar que foi apreendida uma balança de precisão, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, balanças desse tipo são utilizadas para quantificar as porções que serão vendidas. Anoto que a perícia de fls. 152/154 apontou a eficácia da balança, que apresentava boa precisão na medição do peso.

Com relação ao dinheiro apreendido (R\$ 20,00), o acusado Jhonata confirmou que era proveniente do tráfico e o corréu Wesley confessou em juízo que havia acabado de adquirir uma porção de droga, pagando R\$ 20,00 para Jhonata.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente tenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, os réus foram denunciados porque traziam consigo os entorpecentes.

Portanto, a prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria do crime por parte dos réus, no crime ora apurado. Lembre-se que, no caso, não se exige o chamado "dolo específico", mas apenas o dolo genérico, restando evidente que traziam consigo a droga descrita na denúncia, para entrega a consumo de terceiros.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios.

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, os acusados traziam consigo 6.891,7 gramas de maconha, substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta dos réus encontram tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora os acusados tenham alegado que eram usuários de droga, tais alegações não restaram comprovadas, pelo contrário, foram afastadas pela prova colhida durante a instrução, que confirmou a prática do tráfico de drogas pelos acusados.

Ademais, a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental que demonstrassem sua alegação. Ademais, os réus demonstraram-se lúcidos em seus interrogatórios.

Por outro lado, ainda que se admitisse os acusados como usuários, esse fato, por si só, não lhe impede de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas: se os réus são usuários há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias

tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário de droga não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito e passo à aplicação das penas.

Os acusados ostentam mau antecedente (fl. 271 – Processo nº 3000101-25.2012.8.26.0338 (Jhonatan) e fl. 275 – Processo nº 0022789-77.2012.8.26.0032 (Wesley)), razão pela qual uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhes são favoráveis, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Afora isso, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução da considerável quantidade de droga no mercado (nada menos do que 6891,7 gramas de maconha), que, se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes.

Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das conseqüências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e conseqüências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repressão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em conseqüência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC – 687055624 – Rel. Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154)

PENA – Agravantes – Tráfico de entorpecentes – Associação – Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível “reformatio in pejus”, a pena cominada na r. sentença deve prevalecer – Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 23.8.2007 – V.U. – Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, nos aspectos acima relatados (mau antecedente e quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 2/3 (dois), resultando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, quanto ao acusado Wesley, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Referente ao réu Jhoantan, reconheço a agravante da reincidência (fl. 270 – Processo nº 0000031-88.2014.8.26.0338), no entanto, fica compensada com a atenuante

da confissão espontânea, permanecendo as penas em seu patamar inicial. Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar apelação interposta em ação penal que tramitou por este Juízo, decidiu sobre o acerto da referida compensação e a manteve, conforme parte voto que segue:

“... Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 59/69) e a atenuante da confissão foram compensadas, de modo que as reprimendas permaneceram nos patamares iniciais de quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa” (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.282738-3, Comarca de Birigui, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 25.02.2010, v.u.).

Na terceira fase, não é caso de incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque restou demonstrado, por todos os elementos acima descritos, bem como pela apreensão de grande quantidade de droga (nada menos do que 6891,7 gramas de entorpecentes), que os acusados se dedicavam à narcotraficância em escala expressiva, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicavam a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.

Neste sentido, já se decidiu:

“ Sem incidência , porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de sessenta e cinco invólucros), sua natureza (crack) e forma de ação desenvolvida - para fim de venda a indeterminado número de pessoas - antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa.”

Em outros termos, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, razão pela qual não faz jus à redução em questão.

Torno definitiva a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Diante da gravidade das condutas, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), as penas devem ser cumpridas no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois o crime de tráfico é equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos acusados, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais, nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

Os acusados deverão continuar a responderem presos por este processo, pois assim permaneceram durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JHONATA CRISTOFER DA SILVA FERRAZ E WESLEY CARLOS FIGUEIREDO SOARES, qualificados nos autos, ao cumprimento das penas de 08 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07) e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), por infração ao artigo 33,

caput, da Lei nº 11.343/06.

Consigno que os acusados ficaram presos cautelarmente desde 06/07/21 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar as condenações totais constantes do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (deseestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem esses argumentos, as penas fixadas ultrapassam quatro anos, os acusados são reincidentes e Jhonatan ostenta mau antecedente em crime de tráfico, além do que os réus foram presos com considerável quantidade de droga, o que afasta também a substituição da pena privativa de liberdade, que não seria suficiente para a prevenção e repressão do crime. Afora isso, o réu Jhonatan é reincidente específico, o que afasta também a aplicação do § 3º do artigo 44 do Código Penal. Os réus deverão continuar a responderem presos por este processo, pois suas prisões em flagrante foram convertidas em prisão preventiva, conforme decisão proferida às fls. 80/86, a cujos fundamentos me reporto, como razão de decidir. Por fim, anote-se que os réus traziam consigo grande quantidade de droga, o que

traria efeitos altamente lesivos à sociedade e só vem confirmar a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar, para garantia da ordem pública.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada e realizada às fls. 80/86 e 173, respectivamente, nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Como não restou provada a procedência lícita do dinheiro apreendido à fl. 22, não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecente, razão pela qual, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro depositado à fl. 131.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado (dinheiro), instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto aos objetos apreendidos (balança de precisão, chaves e saco vazio), apesar de serem instrumentos do tráfico de drogas praticados pelos acusados, diante da sua natureza, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro e destruição dos objetos apreendidos, instruindo-se o ofício com as cópias.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA